

1501801-71.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... notas e anotações que aparentavam ser do tráfico. Alex disse que era do tráfico e que as meninas não sabiam. Dentro da sacola que estava com Alex acreditava que era droga, mas não era e sim dinheiro. Encontrou R\$ 2.000,00 em uma das tomadas. No total foram apreendidos R\$ 12.000,00.

Por fim, a ré Karina, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio. Assim, como a ré ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501801-71.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2217801/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 19565590 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE,

132/21/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 132/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE,

2217801 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

ALECSANDRO ARAUJO HENQUES, EMELYN ESTER BRITO RIBEIRO e KARINA CAMPELO TEIXEIRA DE MORAES

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou ALECSANDRO ARAUJO HENQUES, EMELYN ESTER BRITO RIBEIRO e KARINA CAMPELO TEIXEIRA DE MORAES, qualificado nos autos, como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06, porque no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 8 horas, na Travessa Cruzeiro, nº 97, casa 3, Jardim Santo André, nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: segundo apurado, policiais civis

receberam notícias de que indivíduo identificado como Alex, conhecido como "Bolão", e uma mulher loira seriam os responsáveis pela arrecadação financeira de pontos de vendas de drogas na Favela do Cruzado e na Favela do Amor, ambas nesta cidade. Os policiais identificaram o veículo GM/Celta, placas MUX 0G99, utilizado por ALECSANDRO e passaram a monitorá-lo. Assim, avistaram o indiciado estacionar o automóvel e entrar em um imóvel situado em uma viela. No dia dos fatos, os policiais retornaram ao imóvel e visualizaram as indiciadas chegarem e permanecerem em frente à residência. Em seguida, o indiciado chegou, portando uma sacola, e todos entraram. Os policiais chamaram pelos moradores e, ao se identificarem, visualizaram uma das mulheres tentando fugir pela janela, mas ela foi contida e abordada. Os policiais viram que a porta estava entreaberta e ingressaram no imóvel, que parecia inabitado e possuía apenas uma cama. Sobre a cama, os policiais encontraram diversas notas expostas, bem como duas sacolas contendo cadernos e folhas afetos à contabilidade do tráfico de drogas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12. Os policiais encontraram, na prede do quarto, um cofre dissimulado e, em seu interior, encontraram a quantia de R\$ 2.000,00. Os policiais apreenderam a quantia de R\$ 12.062,00 (fls. 12). Os indiciados admitiram que estavam no local para fazer o fechamento de pontos de venda de drogas da "família" (PCC), identificadas como "loja 2" e "loja 8", sendo certo que KARINA e EMELYN ganhariam R\$ 100,00 pelos serviços prestados. A localização de dinheiro e papéis contendo a contabilidade, demonstra que os indiciados estavam associados com o fim de praticar tráfico de drogas.

Fls. 137/139: decisão determinando a notificação dos acusados. Os acusados foram notificados (fls. 202, 235/236 e 354355) apresentaram defesa preliminar (fls.254/255, 282/287 e 379/382) e a denúncia foi recebida 26/05/2022 (fls.383/387), as rés foram citadas (fls.447 e 461) e o réu Alecsandro não foi encontrado (fls. 439).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e em seguida, as rés foram interrogadas.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Afasto a primeira preliminar de ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, em favor das acusadas, uma vez que entendo não ser direito subjetivo do réu, mas sim, faculdade do Representante do Ministério Público, a sua oferta quando presentes as hipóteses legais, ora, no caso em pauta, houve recusa justificada ao oferecimento da proposta (fls.131).

Neste sentido:

Acordo de não persecução penal - ANPP. Pleito de realização do acordo. Não cabimento após o recebimento da denúncia. Faculdade do Parquet. Recusa devidamente fundamentada. "A possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao Parquet que o oferte." (RHC 161.251-PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

No que tange a segunda preliminar, afasto a mesma.

No caso, o delito de associação ao tráfico é de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Neste sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO ANTERIOR. ELEMENTOS CONCRETOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO". (RHC 94285 / MG - Rel. Min Joel Ilian Paciornik. J. 15/08/2019).

No que se refere ao interrogatório informal supostamente ocorrido das acusadas aos policiais, no momento das prisões em flagrante, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, pois não restou comprovado nos autos, a alegação de que não lhes foram assegurados o direito de permanecer em silêncio.

A respeito da figura da confissão informal, ensina-nos o professor Guilherme de Souza Nucci que: "O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu, quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram" (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 230).

Com efeito, a confissão informal não é prova, ao contrário, não passa de indício capaz de justificar a ação policial e futura propositura da ação penal.

Observo ainda que o fato dos policiais, no momento da abordagem, não advertirem a pessoa suspeita ou investigada quanto ao direito de permanecer em silêncio ("Aviso de Miranda") é causa de nulidade relativa, consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA.

MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R\$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região. 3. Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada. 4. Em relação ao pedido de desclassificação da conduta, o tema não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental. 5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

No que tange a quarta preliminar da presença da ré no interrogatório da corré, não há qualquer prejuízo as acusadas, uma vez que estas permaneceram em silêncio. Assim, como a própria defesa mencionou não há irregularidade, razão pela qual nada a apreciar. Ademais, o art. 191 do Código de Processo Penal prevê expressamente que os interrogatórios sejam realizados separadamente. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito do tema:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS REALIZADO SEPARADAMENTE. ART. 191 CPP. PACIENTE ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Possibilidade de os interrogatórios de corréus serem realizados separadamente, em cumprimento ao que dispõe o art. 191 do Código de Processo Penal. Precedente. 2. O fato de o paciente advogar em causa própria não é suficiente para afastar essa regra, pois, além de inexistir razão jurídica para haver essa distinção entre acusados, a questão pode ser facilmente resolvida com a constituição de outro causídico para acompanhar especificamente o interrogatório do corréu. Assim, e considerando que a postulação é para que se renove o interrogatório com a presença do acusado na sala de audiências, não há falar em ilegalidade do ato ou cerceamento de defesa. 3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. No caso, segundo consta da sentença condenatória, a responsabilidade penal do paciente foi embasada nos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais foram categóricos ao infirmar as versões apresentadas pelos dois acusados em seus interrogatórios, estes harmoniosos entre si. Esses fatos revelam, a toda evidência, a inviabilidade e a inutilidade do pedido formulado nesta impetração. 4. Ordem denegada. (STF, HC 101.021, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9/6/2014).

No mais, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.1), termo de ocorrência (fls.8/11), auto de exibição e apreensão (fls.12/13), laudos periciais (fls.165/171, 172/177, 178/181, 182/185 e 186/189) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria das acusadas em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal. Na fase policial, a testemunha Carlos narrou: que em decorrência de diligências, trabalho de campo e novas informações privilegiadas acerca da denúncia anônima nº. T2107152364 e da apreensão de entorpecentes registrada no Boletim de Ocorrência nº. 125/2021 desta Especializada, chegou ao conhecimento da equipe policial que um indivíduo, de prenome Alex, de alcunha "bolão" e na companhia de uma moça de cabelos loiros, seriam os responsáveis pela arrecadação financeira de pontos de vendas de drogas nas "Favela do Cruzado", no Jardim Cruzado e da "Favela do Amor", situada no Jardim Santa Cristina, ambas comunidades na cidade de Santo André/SP; que a equipe policial logrou identificar o veículo utilizado por Alex, e passou a monitorá-lo, fazendo o acompanhamento do veículo na data de ontem, verificando Alex chegando até as proximidades do local dos fatos, estacionando o veículo e adentrando um imóvel situado em uma viela, identificando o possível local utilizado pela dupla; que na data de hoje a equipe retornou ao local, pela manhã, estabelecendo campana, oportunidade em que puderam verificar que duas mulheres chegaram ao imóvel, entretanto permaneceram ao lado de fora, por aproximadamente dez minutos. Transcorrido o tempo, Alex também chegou ao imóvel, portando uma sacola, e abriu a porta do imóvel, de alumínio, envidraçada; que a equipe policial deliberou por se apresentarem no imóvel e passaram a chamar por possíveis moradores e, após se apresentarem como policiais, verbalizando com clareza, os agentes visualizaram uma das mulheres tentando fuga pela janela do imóvel, sendo

imediatamente contida; que a porta do local estava entreaberta e, então, os agentes deliberaram por ingressar aquele imóvel, que não possuía eletrodomésticos e móveis em seu interior, com exceção de uma cama, claramente inabitado; que os outros indivíduos foram contidos pela equipe e, sobre a cama, diversas notas encontravam-se expostas, assim como duas sacolas contendo em seu interior cadernos e folhas afetas a contabilidade do tráfico de drogas; que qualificados como ALECSANDRO ARAUJO HENQUES, KARINA CAMPELO TEIXEIRA DE MORAES e EMELYN ESTER BRITO RIBEIRO, todos admitiram ali estarem para fazer o fechamento de pontos de venda de drogas da "família", alusivo ao PCC, identificadas como "loja 2" e "loja 8", e que KARINA e EMELYN teriam sido chamadas para auxiliá-lo, e que ganhariam R\$ 100 reais pelos serviços prestados. Foi dada voz de prisão aos três indivíduos ali contidos; que na parede do quarto havia uma espécie de cofre dissimulado como tomada sem o espelho encaixado, com remendo no entorno e, em seu interior, cerca de R\$ 2.000,00 estavam armazenados.

Em juízo, a testemunha Carlos disse que um pouco tempo antes da ocorrência, uma outra equipe fez uma apreensão de entorpecente no local. Chegou informação que as pessoas responsáveis pela arrecadação de drogas e valor recebido seria um tal de Alex Bolão. Ele estaria envolvido com uma moça loira.. Eles arrecadavam e iam aquele endereço. Passou a diligenciar na região e soube que "Bolão" usava um Celta verde. Três dias antes dos fatos, visualizou o veículo e o seguiu. Ele parou e adentrou em uma viela, a qual dá acesso a um escadão. Foi atrás, mas não viu em qual casa Alex ingressou. No dia seguinte, foi ao local e observou. Chegaram duas moças, pararam no local, ficaram sentadas conversando. Minutos depois, chegou Alex e todos ingressaram na casa. Alex segurava uma sacola e até acreditava ser entorpecente. Avançou e chegou até o portão. Chamou. Percebeu que uma moça foi até a janela. César foi até a porta e ingressou. Foi pela janela. Na casa não tinham móveis e ninguém morava. Eles estavam os três na cama. Várias notas, folhas e cadernos estavam na cama. E em conversa informal eles admitiram que estavam fazendo o "fechamento". Existiam vários recibos com valores. Não conhecia os acusados. Foi apreendido no total R\$ 12.000,00 sendo que em uma tomada sem espelho foi localizado R\$ 2.000,00

A testemunha César, na fase do Inquérito Policial afirmou que que em decorrência de diligências, trabalho de campo e novas informações privilegiadas acerca da denúncia anônima nº. T2107152364 e da apreensão de entorpecentes registrada no Boletim de Ocorrência nº. 125/2021 desta Especializada, chegou ao conhecimento da equipe policial que um indivíduo, de prenome Alex, de alcunha "bolão" e na companhia de uma moça de cabelos loiros, seriam os responsáveis pela arrecadação financeira de pontos de vendas de drogas nas "Favela do Cruzado", no Jardim Cruzado e da "Favela do Amor", situada no Jardim Santa Cristina, ambas comunidades na cidade de Santo André/SP; que a equipe policial logrou identificar o veículo utilizado por Alex, e passou a monitorá-lo, fazendo o acompanhamento do veículo na data de ontem, verificando Alex chegando até as proximidades do local dos fatos, estacionando o veículo e adentrando um imóvel situado em uma viela, identificando o possível local utilizado pela dupla; que na data de hoje a equipe retornou ao local, pela manhã, estabelecendo campana, oportunidade em que puderam verificar que duas mulheres chegaram ao imóvel, entretanto permaneceram ao lado de fora, por aproximadamente dez minutos. Transcorrido o tempo, Alex também chegou ao imóvel, portando uma sacola, e abriu a porta do imóvel, de alumínio, envidraçada; que a equipe policial deliberou por se apresentarem no imóvel e passaram a chamar por possíveis moradores e, após se apresentarem como policiais, verbalizando com clareza, os agentes visualizaram uma das mulheres tentando fuga pela janela do imóvel, sendo imediatamente contida; que a porta do local estava entreaberta e, então, os agentes deliberaram por ingressar aquele imóvel, que não possuía eletrodomésticos e móveis em seu interior, com exceção de uma cama, claramente inabitado; que os outros indivíduos foram contidos pela equipe e, sobre a cama, diversas notas encontravam-se expostas, assim como duas sacolas contendo em seu interior cadernos e folhas afetas a contabilidade do tráfico de drogas; que qualificados como ALECSANDRO ARAUJO HENQUES, KARINA CAMPELO TEIXEIRA DE MORAES e EMELYN ESTER BRITO RIBEIRO, todos admitiram ali estarem para fazer o fechamento de

pontos de venda de drogas da "família", alusivo ao PCC, identificadas como "loja 2" e "loja 8", e que KARINA e EMELYN teriam sido chamadas para auxiliá-lo, e que ganhariam R\$ 100 reais pelos serviços prestados. Foi dada voz de prisão aos três indivíduos ali contidos; que na parede do quarto havia uma espécie de cofre dissimulado como tomada sem o espelho encaixado, com remendo no entorno e, em seu interior, cerca de R\$ 2.000,00 estavam armazenados.

Em juízo, a testemunha César disse que recebeu informação que uma pessoa em companhia de mulheres poderia estar fracionando entorpecente no local. Alex usava um Celta verde e usava uma casa. Seguiu Alex e Carlos, mas não conseguiu ver a casa que ele entrou, mas viu uma viela. No outro dia dicou em campana em outra rua. Viu duas moças chegarem e ficarem em frente do imóvel. Logo depois, chegou as moças. Foi ao local, as portas estavam abertas. Entrou no local. Carlos ingressou pela janela. A casa não tinha móveis. Só uma cama, na qual estavam espalhadas várias notas e anotações que aparentavam ser do tráfico. Alex disse que era do tráfico e que as meninas não sabiam. Dentro da sacola que estava com Alex acreditava que era droga, mas não era e sim dinheiro. Encontrou R\$ 2.000,00 em uma das tomadas. No total foram apreendidos R\$ 12.000,00.

Por fim, a ré Karina, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio. Assim, como a ré Emilyn.

Pois bem, o art. 35 da Lei de Drogas prevê que: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Tal delito exige duas pessoas agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, 34 desta lei.

Assim, necessária a estabilidade e permanência para a caracterização da infração penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de reavaliação probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum para o corréu, a teor do art. 580 do CPP. (STJ - HC: 270837 SP 2013/0159054-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015).

No caso, foram apreendidos, em residência desabitada, na qual estavam as rés, quantia vultuosa, em notas pequenas de dinheiro. Ademais, também foram encontradas anotações do tráfico, em diversos papéis que conforme depoimentos dos policiais estavam espalhados pela cama. Acrescenta-se ainda que os policiais relatam que procederam investigações prévias em relação a terceira pessoa que também estava no imóvel e que segundo "denúncias anônimas" praticava o tráfico no local, com o veículo Celta, verde.

Ora, as acusadas não apresentaram qualquer justificativa para estarem no local, a origem do dinheiro e anotações localizadas, prova esta que lhe pertenciam, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, demonstrado o vínculo associativo entre os agente.

Ademais, a ausência da apreensão da droga, não descaracteriza o delito.

Neste sentido:

A ausência de apreensão de drogas na posse direta do paciente não afasta a prática dos delitos ou sua flagrância, sobretudo em relação a associação ao tráfico. (...)

Estas circunstâncias, aliadas ao resultado da busca e apreensão, tornaram legítimas as prisões procedidas, uma vez que os crimes então investigados são permanentes e, portanto, a consumação perdura mesmo no momento em que o agente não está na posse direta de drogas. Ademais, a configuração da associação para o tráfico não depende de apreensão de drogas na posse direta do agente. (HC 441.712/SP, j. 21/02/2019). Assim, como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssomos no sentido de que as rés praticaram o delito descrito na denúncia. Relataram detalhes das investigações, logo, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Ademais, eventuais pequenas contradições nos depoimentos dos policiais são irrelevantes.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma:

As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca JUTACRIM-SP 67/311).

Acrescenta-se ainda que não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, acusarem as rés da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no mesmo. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que as rés efetivamente praticaram a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, as acusadas eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-las.

Passo a fixar a pena da acusada Karina Campelo Teixeira de Moraes.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais

do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a acusada é primária); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase de aplicação de pena, não há causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e, primariedade da acusada.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTES PRIMÁRIOS, CONDENADOS A PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, NÃO HÁ MAIS QUE SE FALAR EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Confirmada a sentença condenatória pelo Tribunal de origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), em princípio seria possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importasse em violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Antes de se afirmar pela possibilidade ou não da execução provisória da pena, deve-se analisar as alegações defensivas de fixação do regime prisional mais gravoso e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com fulcro apenas na gravidade abstrata do delito. 3. Hipótese em que o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena basearam-se em alegações genéricas acerca da gravidade do delito. 4. O quantum da condenação (3 anos de reclusão), a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais permitem aos pacientes iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, ambos do Código Penal. 5. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar o regime inicial aberto, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. Em consequência, não há mais que se falar em execução provisória de penas restritivas de direitos. (STJ - HC: 521935 SP 2019/0208610-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019).

No caso dos autos, a acusada satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. Verifica-se que a ré não possui personalidade voltada para a prática criminal e a substituição será suficiente para reprovação do crime, considerando que o objetivo final da Lei Penal é impedir novas práticas delitivas, bem como a utilidade em garantir que a criminosa não volte a delinquir pelo temor da aplicação da pena. Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade do crime em tela por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à época do fato, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, até data do efetivo pagamento, e na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções, conforme o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Passo a fixar a pena da acusada Emelyn Éster Brito Ribeiro.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem

considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a acusada é primária); conduta social(nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime(normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da menoridade (16/09/2000 - fls. 50), contudo, deixo de reduzir a pena, uma vez que nesta fase a sanção não pode ficar aquém do mínimo em conformidade com o enunciado da Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, não há causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, primariedade da acusada e a menoridade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTES PRIMÁRIOS, CONDENADOS A PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, NÃO HÁ MAIS QUE SE FALAR EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Confirmada a sentença condenatória pelo Tribunal de origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), em princípio seria possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importasse em violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Antes de se afirmar pela possibilidade ou não da execução provisória da pena, deve-se analisar as alegações defensivas de fixação do regime prisional mais gravoso e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com fulcro apenas na gravidade abstrata do delito. 3. Hipótese em que o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena basearam-se em alegações genéricas acerca da gravidade do delito. 4. O quantum da condenação (3 anos de reclusão), a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais permitem aos pacientes iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, ambos do Código Penal. 5. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar o regime inicial aberto, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. Em consequência, não há mais que se falar em execução provisória de penas restritivas de direitos. (STJ - HC: 521935 SP 2019/0208610-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019).

No caso dos autos, a acusada satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. Verifica-se que a ré não possui personalidade voltada para a prática criminal e a substituição será suficiente para reprovação do crime, considerando que o objetivo final da Lei Penal é impedir novas práticas delitivas, bem como a utilidade em garantir que a criminosa não volte a delinquir pelo temor da aplicação da pena. Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade do crime em tela por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à época do fato, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, até data do efetivo pagamento, e na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções, conforme o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR EMELYN ESTER BRITO RIBEIRO e KARINA CAMPELO TEIXEIRA DE MORAES pelo

delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto e o pagamento de 700 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Substituo as penas privativas de liberdade do crime em tela por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à época do fato, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, até data do efetivo pagamento, e na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções, conforme o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Defiro as rés o direito de recorrer em liberdade, considerando que as acusadas foram condenadas a pena a ser cumprida em regime aberto.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 63 da Lei Federal nº 11.343/2006, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do delito serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos objetos apreendidos (fls. 12/13), eis que claramente utilizados para a prática do delito, oficiando-se à FUNAD.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando as condenações das rés.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 22 de agosto de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA